

1501156-29.2022.8.26.0599

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Flavia de Cassia Gonzales de Oliveira

Comarca: Piracicaba

Foro: Foro de Piracicaba

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 12/12/2022

... condição de dependente químico não elide a prática do delito de tráfico de drogas." (TJAC - Processo: EI 10414920108010001 AC 0001041-49.2010.8.01.0001 -

Relator(a): Pedro Ranzi - Julgamento: 27/04/2011 - Órgão Julgador: Tribunal Pleno - Publicação: 30/04/2011).

"APELAÇÃO. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PROVA. SUFICIÊNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Piracicaba

Foro de Piracicaba

2ª Vara Criminal

Rua Bernardino de Campos, 55, Sala 7, Alemães - CEP 13417-100, Fone: (19) 3372-3084, Piracicaba-SP - E-mail: piracicaba2cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo Digital nº:

1501156-29.2022.8.26.0599

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante - 2208803/2022 - GOE-DEIC-DEINTER 9

Autor:

Justiça Pública

Réu:

FERNANDO NASCIMENTO DE JESUS

Vítima:

Saúde Pública

Artigo da Denúncia:

*

Réu Preso

Tramitação prioritária

Aos 12 dias do mês de dezembro de 2022, à hora designada, por meio da Ferramenta Microsoft Teams, nos termos do Comunicado CG 284/2020, apresentaram-se a Exma. Sra. Dra. FLAVIA DE CASSIA GONZALES DE OLIVEIRA, MM. Juíza de Direito, o representante do Ministério Público, Dr. Paulo Kishi e a Defensora Pública, Dra. Daniela Batalha Trettel. Apresentados o acusado FERNANDO NASCIMENTO DE JESUS e as testemunhas arroladas em comum pelas partes Rogerio José da Silva e Fabio Luis Gonçalves Hilsdorf.

Fica consignado que foi assegurado o direito de entrevista do acusado com sua defensora, em reunião virtual apartada, no estrito cumprimento do artigo 185, § 5º, do C.P.P., tendo a MM Juíza feito ao acusado a observação determinada no artigo 186 do Código de Processo Penal.

INICIADOS OS TRABALHOS, com a concordância das partes, pela MM. Juíza foram colhidos os depoimentos das testemunhas em comum (Rogerio e Fabio) pelo sistema virtual e, em seguida, interrogado o réu.

Em seguida, pela MM Juíza foi deliberado:

"Não havendo mais provas a serem produzidas, encerro a instrução, determinando às partes que passem aos debates orais:

Dada a palavra ao ilustre representante do Ministério Público, manifestou-se sua Excelência nos seguintes termos:

"MM.Juiza, FERNANDO NASCIMENTO DE JESUS está sendo processado pela prática do delito descrito no art. 33, caput, c.c. artigo 40, inciso III, da Lei nº 11.343/06 porque, no dia 02 de agosto de 2022, por volta de 10h40, no cruzamento das ruas Pau Brasil com a rua das Oliveiras, bairro Bosque dos Lenheiros, nesta cidade e comarca, trazia consigo e tinha em depósito 14 (catorze) invólucros contendo cocaína, com peso líquido de 3,1g (três gramas e um decigrama) e 11 (onze) porções de maconha, com peso líquido de 16,5g (dezesesseis gramas e cinco decigramas), destinados à mercancia ilícita ou entrega de qualquer forma a consumo de terceiras pessoas, substância entorpecente que determina dependência física ou psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

O réu foi notificado (fls. 98/99), a Defensoria Pública apresentou defesa prévia (fls. 103/104) e a denúncia foi recebida (fls. 111/113).

Os fatos imputados na exordial acusatória foram comprovados ao longo da instrução criminal, pelo que a ação é procedente.

A materialidade foi comprovada através do boletim de ocorrência (fls. 09/11), auto de exibição/apreensão (fls. 14/15), laudo de exame químico-toxicológico (fls. 79/81), gravação em vídeo (link às fls. 24) e fotografias (fls. 16 e 25/31).

A autoria, da mesma forma, é indubitosa.

Segundo se apurou, na data dos fatos, policiais civis do GOE – Grupo de Operações Especiais investigavam a venda de drogas em local já conhecido pela por essa prática ilícita, permanecendo um dos milicianos em viatura descaracterizada em observação no cruzamento das ruas Pau Brasil com a rua das Oliveiras, enquanto os demais policiais aguardavam nas imediações do bairro. Nessas circunstâncias, FERNANDO foi visto por diversas vezes em atitude típica do comércio de drogas, pois se aproximava de outras pessoas, recebia algo e, ato seguinte, pegava algo que estava escondido na calçada e entregava ao interlocutor.

As características físicas e de vestimentas do denunciado foram repassadas aos demais policiais civis, que realizaram abordagem.

Em revista pessoal, na posse de FERNANDO foi localizado 01 (um) invólucro contendo maconha, além de R\$ 9,00 (nove reais) em cédulas de pequeno valor. No local em que o denunciado foi visto retirando algo para entregar aos interlocutores, os policiais localizaram outros 10 (dez) invólucros de maconha, embalados do mesmo modo, além de 14 (catorze) invólucros plásticos contendo cocaína.

O local em que FERNANDO realizava o comércio ilícito de drogas está há menos de 50 metros da Escola Municipal Professor Luiz de Siqueira, como demonstrado na denúncia.

As circunstâncias apuradas, local da prisão, apreensão de porções individualizadas e flagrante de comércio ilícito, evidenciam que a droga apreendida destinava-se à mercancia ilícita ou entrega de qualquer forma a consumo de terceiras pessoas. Com efeito, a testemunha Rogério José da Silva, policial civil do GOE, disse em solo policial que "realizava investigação visando a ilícita atividade do comércio ilícito de entorpecentes; esclarece que dividiram as funções, e, seu colega de serviço Fábio foi responsável pela observação discreta e permaneceu observando o cruzamento entre as Ruas Pau-Brasil, esquina com a Rua das Oliveiras, bairro Bosque dos Lenheiros; trata-se de local já conhecido como ponto onde ocorre o ilícito comércio de entorpecentes; esclarece que tomou conhecimento que seu colega de serviço Fábio acabou constatando que indivíduo de cor branca, vestindo bermuda colorida, camiseta vermelha e um chapéu de palha, sendo certo que tal indivíduo acabou mantendo contato por duas vezes, uma com um motociclista e outra com um ciclista; esclarece que foi possível observar movimento de troca, ou seja, ele recebia algo da pessoa, buscava algo que estava na calçada, onde se abaixava e retirava algo, retornava e entregava para a pessoa com a qual mantinha contato; esclarece que seu colega Fábio, diante dos elementos que evidenciavam que o indivíduo estava realizando o ilícito comércio de entorpecentes, telefonou para o depoente que então se deslocou até o local indicado, e, de posse das

características físicas e vestimentas do indivíduo e local onde ele se abaixava e retirava a droga; esclarece que foi responsável pela realização de abordagem e revista pessoal, sendo que localizou a quantia de R\$9,00 (nove reais composta por cédulas de pequeno valor), bem como um invólucro plástico transparente contendo em seu interior erva esverdeada, aparentando se tratar de maconha; acrescenta que no local onde Fábio informou que o indivíduo retirava algo, encontrou 14 invólucros plásticos transparentes contendo em seu interior substância em pó de cor branca aparentando se tratar de cocaína e, ainda, outros 10 (dez) invólucros plásticos contendo também erva esverdeada, aparentando se tratar de maconha, invólucros que ostentavam as mesmas características daquele encontrado em poder do autuado; o depoente esclarece que o autuado não se manifestou a respeito do dinheiro, substância entorpecente e circunstâncias de sua prisão; esclarece que diante dos fatos, foi proferida voz de prisão ao autuado, havendo necessidade de utilização de algema tendo em vista o fundado receio de fuga, já que tal indivíduo passou a debater com a equipe e se postar de forma a relutar contra a ação, depois que percebeu que seria conduzido às dependências desta unidade policial; tem ainda a esclarecer que conseguiu realizar uma filmagem que evidencia cabalmente uma das cenas que observou que evidenciam claramente o movimento de troca que denota a efetiva prática do comércio ilícito de entorpecentes por parte do autuado; esclarece que cerca de quinze metros do local da abordagem, há uma Creche municipal localizada na Rua Pau-Brasil, de nome Escola Municipal Professor Luiz de Siqueira; esclarece que seu colega Fábio realizou filmagem do local." (fls. 03/04). Em juízo ratificou integralmente o depoimento prestado na fase policial. Não conhecia o réu.

No mesmo sentido foram as declarações prestadas pelo policial civil Fábio Luís Gonçalves Hilsdorf (fls. 05/06).

Em juízo, os policiais civis ratificaram o que haviam declarado na fase policial. Em solo policial, o réu permaneceu em silêncio (fls. 08).

Interrogado em juízo, o réu alegou foi surpreendido pelos policiais com o dinheiro e com a droga apreendida. Realmente a droga lhe pertencia e destinava-se a venda. Estava vendendo porque estava devendo. Se não pagasse a dívida seria morto. Foi vender apenas no dia que foi preso. Não conhecia os policiais que o prenderam. Diante do todo apurado há provas suficientes que demonstram que o réu foi autor do delito imputado.

A narrativa dos policiais foi firme e uníssona em confirmar realizaram observação velada com viatura descaracterizada e, nessas circunstâncias, o denunciado foi visto por diversas vezes em atitude típica do comércio de drogas, pois se aproximava de outras pessoas, recebia algo e, ato seguinte, pegava algo que estava escondido na calçada e entregava ao interlocutor. Ato seguinte, as características físicas e de vestimentas do denunciado foram repassadas aos demais policiais civis, que realizaram a abordagem. Feita a revista pessoal, na posse de FERNANDO foi localizado um invólucro contendo maconha, além de R\$ 9,00 (nove reais) em cédulas de pequeno valor. No local em que o denunciado foi visto retirando algo para entregar aos interlocutores, os policiais localizaram outros 10 (dez) invólucros de maconha, embalados do mesmo modo, além de 14 (catorze) invólucros plásticos contendo cocaína.

Toda a ação do denunciado fora gravada em vídeo pelos policiais, demonstrando claramente que ele realizava a venda de entorpecentes (link do vídeo às fls. 24 e imagens às fls. 25/31).

Diante deste quando, resta claro que as drogas apreendidas se destinavam à mercancia ilícita.

Pertinente salientar que não há nada que invalide os depoimentos dos policiais civis, devendo ser valorados como as demais provas constantes no processo.

Neste sentido:

APELAÇÃO. Tráfico de entorpecentes. Artigo 33, caput, da lei nº 11.343/06.

Materialidade e autoria devidamente comprovadas pelo conjunto probatório carreado aos autos. Valor do depoimento testemunhal de servidores policiais que, ratificados em juízo, sob a garantia do contraditório, reveste-se de inquestionável eficácia probatória. Inexistência de contradições ou elementos de convicção que possam

retirar-lhe a credibilidade. Dosimetria da pena mantida. Regime inicial fechado adequadamente imposto. Análise da detração que compete ao Juízo das Execuções Criminais. RECURSO DESPROVIDO. (Apelação nº 3005429- 53.2013.8.26.0320, 15ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Camargo Aranha Filho, j .05/05/2016) – Grifo nosso

Outrossim, também restou comprovado que o local em que o denunciado praticava o comércio ilícito de drogas está há menos de 50 metros da Escola Municipal Professor Luiz de Siqueira:

Destarte, diante do conjunto probatório, imperiosa a condenação do réu pelo delito em questão, com incidência da causa de aumento prevista no artigo 40, inciso III, da Lei nº 11.343/06.

Passo a analisar a dosimetria da pena.

Na primeira fase, as penas devem ser fixadas acima do mínimo legal, pois o réu possui diversos registros de antecedentes criminais.

Na segunda fase, verifica-se que o réu é multireincidente, inclusive específico (autos nº 0012199-74.2014.8.26.0451 – 2ª Vara Criminal da Comarca de Piracicaba).

Na terceira fase, a pena deve ser aumentada em razão da incidência do artigo 40, inciso III, da Lei nº 11.343/06, uma vez que o réu realizava o comércio ilícito de drogas está há menos de 50 metros da Escola Municipal Professor Luiz de Siqueira. Ademais, ante a reincidência, inaplicável o art. 33, § 4º, da Lei de Drogas.

Sendo certa a condenação, o regime inicial deve ser o fechado diante da gravidade concreta do delito, proporcional, necessário e suficiente à prevenção e reprovação dos delitos, além do fato de ser reincidente específico.

Presentes os requisitos para manutenção da prisão preventiva, notadamente garantia da ordem pública, deverá ser indeferido apelo em liberdade.

Requeiro, por fim, seja decretado o perdimento do valor apreendido com o acusado, consistente em R\$ 9,00 reais (nove reais), com fulcro nos artigos 62, §2º, e 63, §§ 1º, 2º, 3º e 4º, da Lei nº 11.343/2006.

Destarte, requeiro seja julgada procedente a ação penal e o réu condenado nos exatos termos da inicial.

Dada a palavra à nobre defensora do acusado, manifestando-se sua Excelência nos seguintes termos:

"MM.Juíza, Fernando Nascimento de Jesus foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, c.c/ a causa de aumento do artigo 40, III, ambos da Lei 11.343/06 (Lei de Drogas).

Segundo a denúncia, em 22 de agosto de 2022, por volta das 10h40, no cruzamento da Rua Pau Brasil com a Rua das Oliveiras, no bairro Bosque dos Lenheiros, neste Município e Comarca de Piracicaba, o denunciado trazia consigo e tinha em depósito 10 porções de maconha e 14 porções de cocaína (laudo de exibição e apreensão – fls. 14-15; laudo químico-toxicológico – fls. 79-81; fotografia – fl. 16).

Ainda conforme a inicial acusatória, policiais civis do Grupo de Operações Especiais (GOE) realizavam atividade investigativa de tráfico de entorpecentes em local conhecido pelo comércio de entorpecentes. Para esse fim, um dos policiais permaneceu em viatura descaracterizada, em atividade de campana, observando o local dos fatos. Os demais policiais aguardavam em local próximo. O denunciado foi avistado por diversas vezes pelo policial à paisana recebendo algo e, ato seguinte, pegando algo que estava escondido na calçada e entregando ao interlocutor. As características pessoais e de vestimenta foram passadas aos demais policiais, que abordaram Fernando.

Com o denunciado, em revista pessoal, foram localizados uma porção de maconha e R\$9,00 em notas diversas. No local na calçada onde ele mexia, foram localizadas 10 porções de maconha e 14 porções de cocaína.

Por fim, consta da denúncia que o local dos fatos fica a aproximadamente 50 metros da escola municipal Professor Luiz de Siqueira.

Interrogado em solo policial, o acusado exerceu o seu direito constitucional ao silêncio (fl. 8).

Às fls. 47-55, juntadas certidão de objeto e pé e folha de antecedentes que indicam

a reincidência do requerido (processo n. 0012199-74.2014.8.26.0451, arts. 33 e 35, LD, pena de 5 anos, em regime inicial fechado, extinta em 25/11/2019; processo n. 1508635-37.2019.8.26.0451, art. 147, CP e art. 21, LCP, pena de 1 mês e 21 dias, regime inicial semiaberto, substituída por pena restritiva de direitos). Ressalte-se que, embora conste da certidão de objeto e pé alguns processos das comarcas de Macaúbal e Pindamonhangaba, tais registros não se repetem na folha de antecedentes e o réu asseverou que não conhece as referidas comarcas e não foi processado nesses locais.

Denúncia às fls. 87-91. Defesa prévia às fls. 103-104.

- DA PRODUÇÃO DE PROVAS NOS AUTOS

A materialidade do delito se comprova pelo laudo de exibição e apreensão (fls. 14-15), pelo laudo químico-toxicológico (fls. 79-81) e pela fotografia (fl. 16).

Com relação à autoria, em audiência de instrução foram colhidos os seguintes elementos:

a) Inicialmente, ouvido o policial civil Rogerio José da Silva. Relatou que o policial Fabio estava fazendo observação velada no local dos fatos, conhecido pelo tráfico. Fabio observou um indivíduo branco, com bermuda colorida, camiseta vermelha e chapéu de palha. Esse indivíduo mantinha contato com uma pessoa de moto e outra de bicicleta. Ele pegava algo da calçada e passava para outras pessoas. Recebeu informações de Fabio com características do rapaz. Em abordagem, encontraram R\$9,00 e uma porção de maconha. Na calçada, onde ele mexia, localizaram 10 porções de maconha e 14 porções de cocaína. A aproximadamente 15 metros do local, há uma creche municipal. Não conhecia o réu. O acusado nada disse sobre os fatos.

b) Em seguida, ouvido o policial civil Fabio Luis Gonçalves Hilsdorf. Estava em campanha em local conhecido pelo tráfico. Viu uma pessoa com roupa colorida, chamou atenção que usava um chapéu de palha. Essa pessoa falou com um ciclista e um motociclista. Ele recebia algo, ia até uma touceira na calçada, mexia, pegava algo e entregava ao interlocutor. Acionou os policiais em viatura caracterizada, que abordaram o réu. Depois, esses policiais passaram que realmente encontraram droga e dinheiro, inclusive na touceira.

c) Por fim, interrogado Fernando Nascimento de Jesus. Confirmou os fatos. Estava mesmo com os R\$9,00 e uma "paranga". As drogas na calçada, 14 porções de "pó" e 10 "parangas" também eram suas. Começou a usar drogas quando estava no semiaberto, foi no sistema prisional que aprendeu a usar. Começou a usar intensamente e a ter problemas com a esposa. Em um dia, havia polícia no bairro, viu os traficantes esconderem droga, aproveitou-se e pegou a droga e o dinheiro. Foi para casa, usou a droga com um amigo. À noite, os traficantes foram na sua casa e disseram que sabiam que foi ele quem furtou a droga. Foi levado ao tribunal do crime, apanhou, disseram que iam matá-lo. O "crime" permitiu que ele pagasse a dívida vendendo as drogas, e estava fazendo esse tráfico no momento em que foi preso. Usava cocaína e, na época, não conseguia ficar sem usar. Tinha começado a vender drogas no dia em que foi preso. Perguntado se residiu em Pindamonhangaba ou Macaúbal, ou foi preso nesses locais, disse que não. Somente respondeu 2 processos em Piracicaba (tráfico e violência doméstica).

- ALEGAÇÕES RELATIVAS À DOSIMETRIA DA PENA

Considerando a confissão do acusado e sua consonância com as demais provas dos autos, passa-se a discorrer acerca da pena.

a) Pena-base

Na remota hipótese de condenação pela prática de tráfico de drogas, de rigor a fixação da pena-base em seu mínimo legal: as consequências e a culpabilidade são normais para o caso, não justificando uma reprovação penal maior.

No mais, as condenações anteriores devem ser avaliadas na segunda fase de fixação de pena, sob pena de bis in idem.

Tais circunstâncias, portanto, recomendam a pena-base no patamar mínimo.

b) Da segunda fase da dosimetria

Na segunda fase dosimétrica, a reincidência deve ser compensada com a confissão, sendo ambas as circunstâncias preponderantes (art. 67. CP).

c) Do afastamento da majorante do art. 40, III, da LD

Adicionalmente, é o caso de afastamento da majorante do artigo 40, III, da Lei de Drogas, posto que não há nos autos comprovação de que o comércio de entorpecentes visava crianças ou adolescentes frequentadores do referido estabelecimento de ensino. Aliás, conforme bem colocaram os policiais depoentes, o local em questão é uma creche municipal, frequentada por crianças de tenríssima idade, fora de qualquer perfil de usuários de entorpecentes.

- REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA

No que tange ao regime inicial, não aplicável ao caso o regime fechado. Em atenção ao disposto no art. 33, § 3º, diante da quantidade pena a ser aplicada e das circunstanciais judiciais, inexistindo fundamentação concreta a recomendar o regime mais gravoso (Súmulas 718 e 719 do STF; Súmula 440 do STJ), de rigor a aplicação do regime semiaberto.

Adicionalmente, para a fixação do regime inicial, não poderá ser observado o disposto no art. 1º, § 2º, da LCH, tendo em vista que a declaração de inconstitucionalidade pelo STF, exercendo sua função típica de guardião da Constituição e, por isso, proferindo uma decisão de observância obrigatória por todo o Judiciário (CF, art. 102 c. c/ art. 927 do CPC).

- DO DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE

Finalmente, deve ser assegurado ao acusado o direito de apelar em liberdade. Com efeito, de acordo com o art. 387, § 1º, do Código de Processo Penal, ao proferir uma sentença de condenação, "O juiz decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento de apelação que vier a ser interposta". Ademais, a decisão pela manutenção da prisão preventiva deve ser concreta, cabendo ao julgador "[...] indicar concretamente a existência de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada" (CPP, art. 315, § 2º). Com efeito, uma vez encerrada a instrução, ainda que se entenda pela manutenção da prisão preventiva anteriormente exposta, a decisão deve ser concretamente fundamentada, visto que ainda vigente o estado de inocência (CF, art. 5º, LVII; CADH, art. 8.2). Em seguida pela MM.Juíza foi dito o seguinte:

Passo a proferir a seguinte sentença:

VISTOS.

FERNANDO NASCIMENTO DE JESUS, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas penas do artigo 33, caput, combinado com o artigo 40, inciso III, da Lei nº 11.343/06, porque no dia 02 de agosto de 2022, por volta de 10h40, em via pública, no cruzamento das ruas Pau Brasil com a Rua das Oliveiras, bairro Bosque dos Lenheiros, nesta cidade e comarca, trazia consigo um invólucro de maconha e tinha em depósito 14 (catorze) invólucros contendo cocaína e 10 (dez) porções de maconha, destinadas à mercancia ilícita ou entrega de qualquer forma a consumo de terceiras pessoas, substância entorpecente que determinam dependência física ou psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar (cf. auto de exibição e apreensão - fls. 14/15; laudo de químico-toxicológico - fls. 79/81; e fotografia - fls. 16).

Segundo a denúncia, na data dos fatos, policiais civis do GOE - Grupo de Operações Especiais investigavam a venda de drogas em local já conhecido por essa prática ilícita, permanecendo um deles na viatura descaracterizada em observação no cruzamento das ruas Pau Brasil com a Rua das Oliveiras, enquanto os demais aguardaram nas imediações do bairro. Nessas circunstâncias, o réu foi visto diversas vezes em atitude típica do comércio de drogas, pois se aproximava de outras pessoas, recebia algo e, ato seguinte, pegava algo que estava escondido na calçada e entregava ao interlocutor.

As características físicas e de vestimentas do réu foram repassadas aos demais policiais civis que realizavam abordagem.

Em revista pessoal, na posse de FERNANDO foi localizado 01 (um) invólucro contendo maconha, além de R\$ 9,00 (nove reais) em cédulas de pequeno valor. No local em que o réu foi visto retirando algo para entregar aos interlocutores, os policiais localizaram outros 10 (dez) invólucros de maconha, embalados do mesmo modo, além de 14 (catorze) invólucros plásticos contendo cocaína.

O local em que o réu realizava o comércio ilícito de drogas há menos de 50 metros

da Escola Municipal Professor Luiz de Siqueira:

A denúncia foi oferecida (fls. 91) sendo determinada a notificação do réu para oferecer defesa prévia, nos termos do artigo 55 da Lei nº 11.343/06 (fls. 92/93). Notificado (fls. 99), o réu apresentou defesa prévia, na qual aduziu a inexistência de questões preliminares, sendo as questões de mérito tratadas ao final da instrução processual e requereu a revogação da prisão preventiva (fls. 103/104). A denúncia foi recebida, designando-se a audiência (fls. 111/113). O réu foi citado (fls. 129).

Durante a instrução, foram ouvidas 02 testemunhas comuns, sendo o réu interrogado. Encerrada a instrução, em memoriais, as partes se manifestaram.

É o relatório.

DECIDO.

A ação penal é procedente.

1) Da materialidade

A materialidade criminosa está consubstanciada no auto de exibição e apreensão de fls. 14/15, na fotografia de fls. 16, no laudo de constatação de fls. 18/23, bem como no exame químico-toxicológico de fls. 79/81, segundo o qual foram detectadas Tetrahydrocannabinol (THC) e cocaína nas substâncias apreendidas.

2) Da autoria

A autoria ficou demonstrada nos autos.

Na fase investigativa, o réu permaneceu em silêncio (fls. 08).

Em Juízo, o réu afirmou que realmente os policiais o abordaram e pegaram com R\$ 9,00 e uma paranga, depois, encontrara o restante da droga, que também era sua. Começou a usar drogas no regime semiaberto. Depois que foi solto, começou a usar drogas. depois de 04 anos solto, começou a usar muita droga. um dia, viu um moleque escondendo a droga e fugindo e acabou pegando-a e indo para casa. usou a droga do moleque. Mais tarde, foram até sua casa com revólver, querendo a droga. conversou com o traficante e foi levado a um Tribunal do Crime. Foi agredido e iria ser morto, mas lhe deram uma oportunidade de vender a droga para pagar a dívida. A droga, então, era para vender e pagar sua dívida. Fazia uso de cocaína e não conseguia ficar sem consumi-la. só tinha vendido drogas naquele dia. Nunca morou em Macaubau e Pindamonhangaba.

A autoria foi comprovada pelos demais elementos de prova. Vejamos.

O policial civil Fábio Luís Gonçalves Hilsdorf narrou que estava em viatura descaracterizada, fazendo monitoramento velado, em local conhecido como ponto de venda de drogas. viu uma pessoa de chapéu de palha entregando alguma coisa e recebendo ela dinheiro. Depois, ele entregou alguma coisa a um ciclista e recebeu alguma coisa. Viu que ele mexia numa touceira, na calçada da creche que existe nas proximidades. Passou essas informações para Rogério. Ele fez a abordagem e encontrou com o réu drogas e dinheiro. No local onde ele mexia, na touceira, havia mais 14 invólucros de cocaína e 10 de maconha. Não teve contato com o réu.

O policial civil Rogério José da Silva relatou que o policial Fábio começou a fazer observação monitorada e velada em local conhecido como ponto de venda de drogas. não havia denúncia contra o réu. Fábio viu o réu mantendo contato com uma pessoa de moto e outra de moto e percebeu que ele pegava algo da calçada e entregava para essas pessoas. Fábio descreveu as vestimentas. Fez a abordagem e verificou com o réu droga e dinheiro. No local onde ele mexia, encontrou mais drogas idêntica àquelas que estavam com ele. O réu nada mencionou sobre as drogas. Existe uma escola a 15 metros de distância do local da abordagem. Não conhecia o réu.

A primeira questão a ser analisada nos autos é o envolvimento do réu com a droga apreendida.

Na Delegacia de Polícia, o réu nada disse. Judicialmente, o réu confirmou que estava na posse e guarda da droga, para venda.

O investigador de polícia Fábio narrou que foi o responsável pelo monitoramento velado, realizado com viatura descaracterizada, em local conhecido por ser ponto de venda de drogas. Durante a visualização, viu que o réu fez contato com um motociclista e uma ciclista, recebendo deles alguma coisa e indo até determinado local, na calçada, abaixava-se, retirava alguma coisa e a entregava ao interlocutor. Fábio avisou os outros policiais que fizeram a abordagem. Na posse do

réu, o policial Rogério encontrou R\$ 9,00 em notas trocadas e 01 invólucro de maconha. Na calçada, onde o réu retirava alguma coisa, ele encontrou 14 porções de cocaína e 10 porções de maconha, embaladas da mesma forma que aquela localizada na posse do réu, que nada mencionou sobre a acusação. Os policiais confirmaram que a 15 metros do local da abordagem havia uma creche municipal.

Além da prova oral, os policiais captaram imagens do réu, em plena atividade ilícita, consoante link de acesso a fls. 24, no qual é possível visualizar o contato que o réu teve com o motociclista. As fotografias juntadas aos autos também revelam a ação do réu, agachando-se junto à sarjeta, local onde a maior parte da droga foi apreendida (fls. 26/28).

Dessa forma, temos apenas uma versão sobre os fatos, no sentido de que o réu tinha envolvimento com a droga apreendida.

Ainda que assim não fosse, como já vem decidindo a jurisprudência, a palavra de policiais, como funcionários públicos que são, tem validade como prova, em especial como no caso dos autos, quando embasada no restante da prova.

Nesse sentido, já se manifestou o Egrégio Superior Tribunal de Justiça:

Ademais, esta Corte tem entendimento firmado de que os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese. (AgRg no AREsp n. 2.096.763/TO, rel. ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022).

ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ELEMENTOS PROBATÓRIOS HÁBEIS À COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES RESPONSÁVEIS PELA APREENSÃO DO MATERIAL PROSCRITO, CORROBORADOS PELOS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. Os depoimentos dos policiais militares representam sólido componente de convencimento e, encontrando respaldo em outros elementos de convicção, podem ser invocados para justificar a condenação. Aliás, na falta de qualquer adinículo de prova, suspeitar da veracidade das declarações dos policiais, que, no cumprimento do seu dever funcional, submetem-se diariamente à situação de risco para atuar no combate à narcotraficância, é inadmissível, traduzindo-se, ainda, em postura com a qual o Poder Judiciário não pode coonestar. (STF - HC: 215166 SC 0119154-54.2022.1.00.0000, Relator: CARMEN LÚCIA, Data de Julgamento: 27/06/2022, Primeira Turma, Data de Publicação: 29/06/2022).

"[...] no que atine à questão da validade dos depoimentos funcionais, esta eg. Corte também é pacífica no sentido de que eles merecem a credibilidade e a fé pública inerente ao depoimento de qualquer servidor estatal no exercício de suas funções, principalmente, quando ausentes indícios de que houvesse motivos pessoais para a incriminação injustificada dos investigados". (HC 705.060/SP, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDF), QUINTA TURMA, julgado em 15/02/2022, DJe 21/02/2022).

(...) 3. Nos termos da orientação jurisprudencial desta Corte, "o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso". Precedentes (AgRg no HC 672.359/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 28/6/2021). (...) (AgRg no AREsp 1934729/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 08/02/2022, DJe 15/02/2022)

Comprovado que a droga era de responsabilidade do réu, a distinção cabível, neste momento processual, é sobre a existência do dolo que comprove a traficância.

O elemento subjetivo do tipo, como diz respeito à intenção do agente, contida em seu interior, não é perceptível logo de início, mas sim aferível por meio das circunstâncias externas que acabam por traduzir o interior do agente. Entende a jurisprudência:

"O aferidor, que marca as fronteiras entre os tipos penais previstos nos artigos 12 e 16 da Lei 6368/76, reside na finalidade com que a erva é guardada, transportada, adquirida ou tida em depósito. Se para exclusivo uso próprio o delito é o do artigo 16 e, caso contrário, se configura do artigo 12" (TJRS - Ver. 695102699 - Rel. José

Eugênio Tedesco - RJTJRS 175/54).

"Para a caracterização do crime de narcotráfico, como em relação aos demais delitos punidos na Lei 6368/76, atender-se-á à quantidade da substância apreendida, ao local e condições em que se desenvolveram a ação criminosa, às circunstâncias da prisão, bem como à conduta e aos antecedentes do agente, tal como dispõe o artigo 37, da referida lei" (TJRS - Ver. - Rel. Rubens Rebelo Magalhães - RJTJRS 74/11). No caso dos autos, o réu alegou que a droga seria para a venda. A prova dos autos indica que a droga tinha como destinação o consumo de terceiros pessoas.

Inicialmente, os policiais realizavam investigação que visava apurar a prática de tráfico de drogas em local dos fatos já conhecido pela existência da venda espúria, quando observaram o réu em típica movimentação de traficância: ele manteve contato com um motociclista e um ciclista, realizando uma troca, na qual recebia algo da pessoa, deslocava-se até a calçada, abaixava-se e retirava algo do chão, retornando e entregando o que havia pegado ao terceiro.

Parte dessa movimentação foi capturada por imagens (fls. 24) e fotografias (fls. 25/31).

A quantidade e diversidade de droga apreendida (14 porções de cocaína e 11 porções de maconha) são superiores àquelas que normalmente são localizadas com usuários de drogas.

A forma de embalagem da droga (em porções menores) também indica a atividade mercantil (fotografia de fls. 16).

Assim, o local da abordagem, o vídeo e as fotografias, a quantidade da droga, sua variedade e forma de embalagem, a confissão judicial; tudo revela que a droga tinha como destinação o consumo de terceiros pessoas.

Ressalto que ainda que o réu seja usuário de entorpecente, a traficância não fica afastada, uma vez que várias pessoas nessas condições acabam por vender entorpecentes até mesmo para sustentar o seu vício ou pagar dívida de drogas. Além disso, a dependência refere-se à imputabilidade e não à caracterização do delito. Diz a jurisprudência:

"A condição de dependente químico não elide a prática do delito de tráfico de drogas." (TJAC - Processo: EI 10414920108010001 AC 0001041-49.2010.8.01.0001 - Relator(a): Pedro Ranzi - Julgamento: 27/04/2011 - Órgão Julgador: Tribunal Pleno - Publicação: 30/04/2011).

"APELAÇÃO. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PROVA. SUFICIÊNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO. PORTE DE ENTORPECENTE. DESCABIMENTO. Acusada que admitiu a venda de entorpecentes. Apreensão de grande quantidade de "crack", aliada às demais circunstâncias do flagrante, que impedem a conclusão de que os entorpecentes se destinassem ao consumo próprio. FIGURA DO USUÁRIO-TRAFICANTE. A condição de dependente químico está relacionada ao conceito de imputabilidade (pressuposto de aplicação da pena) e não interfere na subsunção do fato ao tipo penal. Condição de toxicômano que não elide a conclusão de que a ré se dedicava à narcotraficância. Figura do usuário-traficante amplamente admitida pelos tribunais. Defesa, ademais, que sequer se desincumbiu do ônus de comprovar a alegada dependência química da acusada. Condenação pelo crime de tráfico mantida. RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO." (TJSP - Processo: APL 182718720088260451 SP 0018271-87.2008.8.26.0451 - Relator(a): Amado de Faria - Julgamento: 13/09/2012 - Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal -Publicação: 20/09/2012).

"A simples alegação de o agente ser viciado em drogas não tem o condão de desclassificar a conduta, mormente se surpreendido na posse de grande quantidade de entorpecente, de molde a evidenciar finalidade de venda" (TJRN, Ap. 00.001954-2, Câmb. Crim., j. 1º.06.2001, rel. Juiz João Rebouças, V.U., RT 796/688).

"A alegação de viciado não obsta o reconhecimento da figura do traficante, mormente na hipótese vertente, em que ambas se mesclam num mesmo agente, preponderando à última, de maior gravidade" (TJSP - HC 42.229-3 - Rel. Onei Raphael - RJTJSP 101/498).

"Tráfico de entorpecente - Grande quantidade da droga apreendida em poder do acusado, evidenciadora do propósito de comercialização - Desclassificação para uso, em razão da dependência, inadmissível - Inteligência dos artigos 12 e 16 da Lei n.º 6.368/76" (TJMT - AC 565/86 - Rel. Mauro José Pereira - RT 620/331).

Alegou o réu que estava sendo ameaçado de morte e, por isso, efetuou a venda da droga. sua manifestação, contudo, não há qualquer comprovação dessa suposta ameaça a trazer garantia da situação por ele mencionada.

Assim, sua versão, isolada, não é capaz de afastar sua responsabilização penal. A condenação, assim, é de rigor.

3) Da causa de aumento de pena

Como se verifica do mapa a seguir, o cruzamento onde o réu efetuava o tráfico de drogas encontram-se nas proximidades de Escola Municipal (fls. 89):

A fotografia de fls. 29 também confirma a existência da escola.

Assim, a causa de aumento de pena deve ser reconhecida.

Arguiu a Defesa que não há prova de que a ação do réu tivesse por interesse as pessoas que estudam naquela escola.

Em recente decisão, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça se manifestou no sentido de que não há necessidade de comprovação de que a mercancia visava atingir estudantes ou frequentadores dos lugares descritos, já que se trata de causa de aumento de natureza objetiva.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA. ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. INVIABILIDADE. NÃO ATENDIMENTO DAS DIRETRIZES EXIGIDAS PARA O RECONHECIMENTO DO PRIVILÉGIO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA PROCESSUAL ELEITA. PRECEDENTES. DECOTE DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO INCISO III DO ART. 40 DA LAD. INVIABILIDADE. DELITO COMETIDO PRÓXIMO A ESTABELECIMENTO DE ENSINO. SUFICIÊNCIA. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE INFERIOR A OITO ANOS DE RECLUSÃO. FIXAÇÃO DO REGIME PRISIONAL INICIAL FECHADO. POSSIBILIDADE. VARIEDADE E EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PRECEDENTES.

AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. - Nos termos do art. 33, § 4º da Lei n.º

11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organização criminosa. - A causa especial de diminuição de pena pelo tráfico privilegiado foi negada ao paciente porque a Corte Estadual reconheceu expressamente sua dedicação à atividade criminosa, em razão das circunstâncias que culminaram em sua prisão em flagrante - em local conhecido como ponto de tráfico de drogas, na posse de 20 pinos de cocaína, 2 tijolos de maconha, 4 porções de maconha, além de 2 balanças de precisão. Acrescente-se, ainda, a confissão do paciente sobre sua dívida com os traficantes locais, tendo sido ordenado que guardasse uma mochila com entorpecentes em sua residência, tudo a indicar que ele não figurava como traficante eventual. Ante tais elementos, não faz jus, portanto, à incidência da referida minorante. - Desconstituir tal assertiva, como pretendido, demandaria, necessariamente, a imersão vertical na moldura fática e probatória delineada nos autos, inviável na via estreita do habeas corpus. Precedentes. - No que tange à incidência da causa de aumento de pena prevista no art. 40, III, da Lei n. 11.343/2006, a jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que é suficiente a prática do crime nos locais mencionados no aludido dispositivo, não sendo necessária a comprovação de que o agente possuía a intenção de fornecer as substâncias entorpecentes às pessoas que frequentam os referidos locais. Precedentes. - Apesar de o montante da pena - 5 anos e 10 meses de reclusão -, admitir, em tese, a fixação do regime intermediário, o regime prisional inicial mais gravoso deve ser mantido, haja vista a gravidade concreta da conduta perpetrada, consubstanciada na variedade e expressiva quantidade de drogas apreendidas. Tal entendimento está em harmonia com a jurisprudência desta Corte de Justiça, segundo a qual a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, ou ainda, outra situação que demonstre a gravidade concreta do delito perpetrado, como in casu, é condição apta a recrudescer o regime prisional, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal. Precedentes. - Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 763.678/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/10/2022, DJe de 28/10/2022 - grifei)

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INEXISTÊNCIA. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE AUMENTO DO ART. 40, INCISO III, DA LEI DE DROGAS. CRIME REALIZADO NAS IMEDIAÇÕES DE ESTABELECIMENTO DE ENSINO. INCIDÊNCIA. PENA-BASE. NATUREZA DA DROGA (COCAÍNA E CRACK). ART. 42 DA LEI N. 11.343/2006. REGIME SEMIABERTO. ADEQUAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A prolação de decisão monocrática pelo ministro relator está autorizada não apenas pelo RISTJ, mas também pelo CPC. Nada obstante, como é cediço, os temas decididos monocraticamente sempre poderão ser levados ao colegiado, por meio do controle recursal, o qual foi efetivamente utilizado no caso dos autos, com a interposição do presente agravo regimental. 2. O objetivo da lei, ao prever a causa de aumento de pena do inc. III do art. 40, é proteger espaços que promovam a aglomeração de pessoas, circunstância que facilita a ação criminosa (AgRg no AREsp 1.028.605/SP, DE MINHA RELATORIA, Quinta Turma, DJe 10/8/2018). Assim, tendo o delito sido cometido nas imediações de estabelecimento de ensino, impõe-se a manutenção da incidência da causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso III, da Lei nº 11.343/2006. Precedentes. 3. O aumento da pena-base em razão da natureza da droga apreendida (cocaína e crack) está em consonância com o disposto no art. 42 da Lei n. 11.343/06. 4. Embora a pena final tenha sido fixada em patamar inferior a quatro anos, a existência de circunstância judicial desfavorável autoriza a imposição do regime intermediário. 5. Agravo regimental não provido. (AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.138.631/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/9/2022, DJe de 13/9/2022.)

A causa de aumento, assim, deve ser considerada.

4) Do dispositivo e da pena

Na dosagem da pena, devem ser levadas em consideração as diretrizes do artigo 59 do Código Penal.

Consoante verifica-se dos autos, na certidão de objeto e pé consta condenação na Comarca de Pindamonhangaba (Certidão de fls. 48 - Processo nº 0001206-87.2014.8.26.0445), no entanto, essa condenação não consta da folha de antecedentes (fls. 53/55) e o réu afirmou que não conhece essa cidade. Assim, havendo inconsistência, não é possível saber se se trata da mesma pessoa e, por isso, não há possibilidade e de uso dessa condenação, para efeitos de aplicação da pena. Assim, o réu possui antecedente criminal (Certidão de fls. 50 - Processo nº 1508635-37.2019.8.26.0451), de forma que sua pena-base deve ser calculada acima do mínimo legal: reclusão de 05 anos e 10 meses e 583 dias-multa.

A reincidência (Certidão de fls. 50 - Processo nº 0012199-74.2014.8.26.0451) se compensa com a confissão, mantendo-se a pena-base.

Observo que não há que se falar em bis in idem, porquanto são 02 as condenações definitivas que o réu possui e uma delas foi utilizada na primeira fase de aplicação da pena e, a outra, na segunda fase.

A causa de aumento fará com que haja acréscimo de mais um sexto à pena: reclusão de 06 anos, 09 meses e 20 dias e 680 dias-multa.

A causa de diminuição referida no artigo 33, parágrafo 4º, da Lei nº 11.343/06 não é cabível diante da reincidência do réu.

Não há mais atenuantes, agravantes, causas de aumento ou de diminuição da pena a serem consideradas.

A pena privativa da liberdade cominada ao delito de tráfico de entorpecente há de ser cumprida em regime inicial fechado, uma vez que o delito continua sendo crime equiparado aos hediondos. Além disso, é o réu portador de maus antecedentes e é reincidente, a confirmar que as penas anteriores não foram capazes de trazer a pena a quem do mínimo legal.

Pena final: reclusão de 06 anos, 09 meses e 20 dias, em regime inicial fechado, e 680 dias-multa, diária-mínima.

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal e o faço para CONDENAR FERNANDO NASCIMENTO DE JESUS, qualificado nos autos, como incurso nas penas do artigo 33, caput, combinado com o artigo 40, inciso III, da Lei nº 11.343/06, à pena de reclusão de 06 anos, 09 meses e 20 dias, em regime inicial fechado, e 680 dias-multa, diária-mínima.

O réu não faz jus à substituição da pena privativa de liberdade pela pena

restritiva de direitos, em razão da quantidade da pena aplicada.

O réu está preso e assim deverá continuar caso deseje recorrer desta sentença. É que sua condição profissional (carreto e pintura - fls. 08) e estado civil (união estável - fls. 08) não o prende ao distrito da culpa. Ademais, o réu é reincidente específico. Por fim, o crime de tráfico de entorpecentes, além de ser gravíssimo, está intranquilizando a sociedade, porque contribui para a má formação dos jovens desta comunidade e fomenta a prática de outros delitos contra o patrimônio e contra a vida. Assim, a prisão é necessária para assegurar a aplicação da lei penal e para garantia da ordem pública.

Recomende-se o réu junto à instituição penal que se encontra, servindo-se esta sentença, por cópia digitalizada, como ofício.

Decreto o perdimento do dinheiro apreendido em poder do réu (comprovante de depósito a fls. 78) à União, já que provenientes do tráfico de drogas, nos termos do artigo 63 da Lei nº 11.343/06.

Custas na forma da lei.

Publicada em audiência, saem os presentes intimados.

Cumpra-se.

Ao final, pela MM. Juíza foi feito um breve resumo da sentença e, indagadas as partes, por elas foi dispensado o compartilhamento da sentença por meio da ferramenta TEAMS.

Tendo em vista que o réu manifestou desejo de recorrer da sentença, pela MM. Juíza foi dito: "recebo o recurso interposto pelo réu, devendo a serventia providenciar a remessa dos autos à Defensoria Pública, para apresentar as razões".

Ressalto que toda a instrução criminal foi gravada pela ferramenta Teams que poderá ser acessado pelo SAJ e pelo link de acesso que oportunamente será juntado aos autos.

Lido e achado conforme, vai devidamente assinado. Eu, Maria Helena C.Oliveira, escrevente técnico judiciário, digitei.